

1500071-73.2021.8.26.0621

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... no varejo, anotações de contabilidade do tráfico etc..

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500071-73.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-73.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2008863/2021 - 2º Distrito Policial de Lorena, 15607736 - 2º Distrito Policial de Lorena, 40/21/204 - 2º Distrito Policial de Lorena, 2008863 - DEL.POL.LORENA, 2008863 - 02º D.P. LORENA, 40/21/204 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO APARECIDO CONCEICAO PIRES

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de BRUNO APARECIDO CONCEIÇÃO PIRES, qualificado nos autos, na qual lhe é atribuída a prática dos crimes previstos nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal - CP, pelos fatos narrados na peça inicial de fls. 116/117.

Recebida a denúncia em 11/02/2021 (fls. 121/122), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 144/145). Não sendo caso de absolvição sumária, designou-se

audiência de instrução e julgamento, nos termos do artigo 399, do Código de Processo Penal – CPP (fls. 148/151).

No curso da instrução foram ouvidas as testemunhas, sendo o réu, ao final, interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais em audiência (mídia às fls. 197).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado, nos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa requereu a improcedência da ação penal, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou que fosse reconhecida a atenuante da confissão espontânea, no que tange ao crime do artigo 16, da Lei 10.826/03.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

As materialidades delitivas, dos crimes da Lei de drogas e de armas estão cabalmente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02 e 03); boletim de ocorrência (fls. 09/12); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 13/14); fotografias (fls. 40/47); pelo laudo de constatação provisória do entorpecente (fls. 50/55) e laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 96/101), cujos resultados foram positivos para “cocaína e tetrahidrocannabinol (THC – maconha)”, substâncias listadas na Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações posteriores (Portaria SPTC 143/2017); laudo pericial da arma de fogo e das munições (fls. 167/171), cujo resultado atestou o potencial lesivo desses objetos; bem como pela prova oral produzida.

As provas de autoria são igualmente objeto de certeza por parte deste Juízo, e recai sobre a figura do réu. A começar pelo estado flagrancial. Senão vejamos.

O policial militar Luís Gustavo de Oliveira Rodrigues contou que após receber informação anônima, por meio do disque-denúncia, a respeito de indivíduo com drogas e arma de fogo, e indicação de seu respectivo endereço e o prenome foi até o local averiguar. Lá chegando foi recebido por uma pessoa de nome Natália, a qual lhe franqueou a entrada no imóvel. Nesse momento, visualizou o réu atirar algo pela janela do quarto. De acordo com o depoente, durante a busca foram encontrados nesse mesmo cômodo onde Bruno foi visto dispensando objetos: folhas de papel, contendo anotações escritas aparentando serem relacionadas com o tráfico; embalagens de plásticos, comumente utilizadas para embalar entorpecentes; munições de arma de fogo; além de pinos plásticos, contendo “cocaína”. Na sequência, outros policiais que o acompanhavam na diligência dirigiram-se até o lado externo do imóvel, na direção da janela do quarto, e localizaram um revólver calibre 38, devidamente municiado, de numeração suprimida e mais drogas (porções de “maconha”, já embaladas, e prontas para venda).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar Victor Rodrigues Marques de Melo.

Por sua vez, o réu confessou parcialmente os termos da denúncia, assumindo o posse da arma de fogo, porém, negando a posse dos narcóticos apreendidos. Contou que recebeu dinheiro para guardar a arma de fogo em questão e, por estar passando por dificuldades financeiras à época, acabou aceitando a proposta. Disse que somente na delegacia ficou sabendo das drogas, negando que tivessem no interior do seu apartamento. Questionado, negou que tivesse jogado lado pela janela de seu apartamento. Por fim, contou já conhecia os policiais militares que o prenderam, vez que estes já o haviam abordado anteriormente, todavia, naquela oportunidade, acabou sendo liberado por eles.

Eis, portanto, as provas orais.

Pois bem. Como bem se vê, a prova incriminadora é, de fato, segura.

Inicialmente, cabe registrar que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costume conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, guardas municipais, ou mesmo, qualquer outro agente de segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020);

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que um policial; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso da militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, ele próprio, violá-la, com o fito de incriminar um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só. Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, hipótese destes autos, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país

pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo. Qual pai de família, morador de uma região afastada do centro da cidade, em sã consciência, se apresentaria à autoridade policial e/ou ao juiz, para entregar o morador traficante da sua rua, algoz de um usuário de drogas devedor, o famoso "acerto de contas"?

Diante disso, negar a validade dos testemunhos de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. O mesmo vale para confissão do réu, por exemplo. Não nos encontramos mais nos primórdios do processo penal. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas. Todas são relativas!

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput" do CPP, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisum o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço, é mais um dentre tantos outros vistos no dia-a-dia forense em que o réu, em vão, tenta desacreditar a fala dos agentes da lei, sem produzir sequer um início de prova da que alega.

Veja-se, por exemplo, que a própria amásia de Bruno, em sede policial, infirmou a versão daquele, declarando, inclusive, ter visto os policiais localizando dentro da sua residência pinos de "cocaína", pertencentes ao réu. Frise-se que, na ocasião, Natália fazia-se acompanhar de advogada constituída (p. 07).

Ademais, não se perca de vista que os policiais militares somente foram até aquele endereço pois este era alvo de denúncia anônima, dando conta da guarda de arma de fogo e tráfico de drogas.

Lado outro, observa-se que os policiais militares envolvidos nessa ocorrência mantiveram a mesma narrativa durante toda persecução penal, ao contrário de Bruno que, em solo administrativo, preferiu o silêncio (fls. 08).

Ora, se por um lado, tal postura revela o exercício de um direito assegurado constitucionalmente ao acusado, não podendo ser prejudicado por essa razão, de outro, nesse caso específico, causa estranheza que o réu não tenha levado ao conhecimento da autoridade policial, integrante da polícia civil (como se sabe, distinta daquela que realizou a prisão), a alegada conduta ilegal e irresponsável dos policiais militares.

Anote-se, ainda, que o réu estava igualmente acompanhado de advogada constituída (fl. 25).

De mais a mais, a teor do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal, em todo o processo, o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar estratagemas criados para incriminá-lo, nem mesmo apontou motivo sério que permitisse tal conclusão, diante da ausência de qualquer lastro probatório nesse sentido.

A propósito:

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO (MACONHA, COCAÍNA E CRACK) - OBJETIVA A ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA, ABRANDAMENTO DO REGIME E DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSÍVEL ATENDER AOS PLEITOS - PRISÃO EM FLAGRANTE EM PONTO DE VENDA E NA POSSE DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS - NEGATIVA DO RÉU ISOLADA E ACUSAÇÃO DE EXTORSÃO RECHAÇADAS PELAS DEMAIS PROVAS, EM ESPECIAL DIANTE DOS DEPOIMENTOS SEGUROS E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE - O ÔNUS DA PROVA QUANTO AO ÁLIBI É DO RÉU, NOS TERMOS DO ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CONDENAÇÃO BEM LANÇADA - A PENA FOI FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS TODOS OS ACRÉSCIMOS - A QUANTIDADE DE PENA E A REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA JUSTIFICAM O REGIME FECHADO - RECURSO DESPROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 0001394-33.2016.8.26.0535; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/04/2020; Data de Registro: 16/04/2020) (Ênfase na reprodução).

Ou seja, a narrativa do réu, sem nenhum elemento probatório, não encontra suporte na realidade comprovada pelos elementos dos autos, que as drogas apreendidas estavam parte em seu apartamento e outra parte fora arremessada por ele, pela janela, conforme as declarações das testemunhas, não havendo alternativa ao Juízo que não prestigiar a versão acusatória.

Esclareço, por fim, ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso, como quantidade e diversidade das drogas, apetrechos para venda no varejo, anotações de contabilidade do tráfico etc..

Outro não é o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Recurso defensivo - Autoria e materialidade delitivas comprovadas - Prisão em flagrante e firmes depoimentos dos policiais militares - Desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 - Descabimento - Tipo penal que prevê diversas condutas - Desnecessidade da prova da efetiva mercancia - Condenação mantida - (...) Recurso não provido". (TJSP; Apelação Criminal 1500932-98.2019.8.26.0566; Relator: Roberto Porto; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 10/12/2019; Data de Registro: 12/12/2019) (Ênfase na reprodução).

Desta forma, como se vê, as circunstâncias fáticas não deixam dúvidas acerca da responsabilidade criminal do réu pelos narcóticos apreendidos, bem como da finalidade mercantil destes. Portanto, de rigor o édito condenatório em desfavor do mesmo pelo crime tipificado no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Com relação ao crime da Lei de armas, mais sorte não tem o acusado, posto que confirmado pelo depoimento dos agentes da lei e confessado pelo mesmo. Logo, é incontroverso nos autos que a arma de fogo, com numeração suprimida e municada, estava sob sua responsabilidade.

Como se sabe a exigência legal de regularização desses armamentos não é mera burocracia estatal, é garantia para a própria população que somente pessoas treinadas e psicologicamente preparadas possuam arma de fogo, acessório ou munição.

Ressalto, também, que o crime de posse irregular de arma de fogo, com munições, é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência consolidada do Colendo STJ, "in verbis":

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 12 DA LEI 10.826/03. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...) AGRAVO DESPROVIDO. (...) III - Hipótese na qual a decisão impugnada se coaduna com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/03 é de perigo abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física e sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a posse de arma de fogo, acessório ou munição. (...). Agravo regimental desprovido". (STJ. AgRg no HC 414.581/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 21/03/2018).

Anote-se, outrossim, que para configuração desse delito, basta a vontade livre e consciente de possuir esses armamentos sem a devida autorização legal, o que ficou evidente no presente caso, diante do depoimento das testemunhas de acusação e a confissão espontânea do réu.

Assim, outro não é o entendimento do E. TJSP, que não a condenação do réu:

"POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO e MUNIÇÕES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito - Validade da fala dos policiais - Versão exculpatória não comprovada nos autos - Manutenção da condenação - Pena e regime corretamente fixados - Recurso improvido (voto nº 44206)". (TJSP; Apelação Criminal 1502635-11.2019.8.26.0616; Relator (a): Newton Neves; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/04/2021; Data de Registro: 22/04/2021).

E não é demais destacar que o laudo pericial acostado aos autos (fls. 167/171) atestou que as munições foram percutidas, detonadas e deflagradas, sendo que a arma de fogo, cuja identificação fora suprimida, mostrou-se apta a realizar disparos, nos testes, a fim de comprovar, eficazmente, o potencial lesivo, das mesmas.

Importante mencionar também, já que o réu afirmou que estava guardando o armamento somente para receber ajuda financeira, ainda que não alegado expressamente pela sua defesa, que dificuldades econômicas não configuram a excludente de ilicitude, do artigo 23, do Código Penal.

Isto porque, o acusado não trouxe qualquer elemento que permitisse aferir que tivesse de fato agido por estado de necessidade, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 156, "caput", do Código de Processo Penal, como acima já exposto.

De outra parte, forte no artigo 24, do Código Penal, não se insere no conceito de estado de necessidade a prática da conduta tipificada na Lei de armas por dinheiro, como asseverado por esse increpado em sua autodefesa, visto que somente deve ser reconhecida aquela excludente diante da sua involuntariedade e estado atual, o que não ocorre neste caso, dado que pendências financeiras são contraídas por livre e

espontânea vontade, havendo outras formas de quitá-las com o passar do tempo.

Neste sentido, o mesmo entendimento recente do nosso Tribunal:

“Apelação. Crime de posse ilegal de arma de fogo irregular. Absolvição por insuficiência de provas. Não cabimento. Materialidade e autoria demonstradas. Excludente de ilicitude do estado de necessidade. Não cabimento. Não provimento ao recurso”. (TJSP; Apelação Criminal 1500355-72.2020.8.26.0603; Relator (a): Zorzi Rocha; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Birigui - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/12/2021; Data de Registro: 07/12/2021) (Sublinhado na reprodução).

Destarte, comprovada a versão acusatória da exordial, pelos depoimentos e confissão do acusado, a única solução para o presente caso é a censura do réu também por este delito.

Passo às penas.

a) Crime do artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06:

Na primeira fase, conforme documentos de fls. 186/189 e 191/193, folha de antecedentes e certidão criminal, respectivamente, verifico que o réu possui uma única condenação, pelo mesmo crime da Lei de drogas, com trânsito em julgado em 12/03/2020, pelo processo 0001055-73.2017.8.26.0621, configuradora da reincidência. Logo, deixo de valorada nesta etapa.

Contudo, a quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos (716,69 gramas, massa líquida, de “maconha”; e 28,85 gramas, também massa líquida, de “cocaína”) apontam para maior risco ao bem jurídico tutelado por este tipo penal (saúde pública), não podendo este julgador, aplicar a mesma sanção devida à culpabilidade normal à espécie.

Ademais, saliente-se que foram apreendidos diversos apetrechos comumente utilizados pelo tráfico de droga, que indicam que o réu não apenas guardava os entorpecentes, como também os preparava e distribuía, em linha com a informação anônima recebida pelo “disque-denúncia”.

Logo, sua pena base deve ser fixada em 1/6 (um sexto) acima do piso legal, ou seja, em 05 anos e 10 meses de reclusão e ao pagamento de 583 dias-multa.

Na fase intermediária, como mencionado acima, à luz da sua reincidência, frise-se, específica, forte no artigo 61, inciso I, do Código Penal, agravo as sanções em 1/5 (um quinto), finalizando-as em 07 (sete) anos e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Como se trata de reincidência específica, justifica a fração acima agravada, dado que a condenação anterior, pelo mesmo crime destes autos, não fora suficiente para ele assimilar a desaprovação social e absorver de forma adequada a terapêutica penal que lhe foi imposta, demandando maior rigor no momento da fixação desta sanção, em obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade.

A propósito:

“Apelação da Defesa - (...) Reincidência específica do acusado a demonstrar a maior gravidade da conduta - Necessário maior rigor no momento da fixação da pena - Obediência aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade - (...) Recurso de apelação desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 0001575-22.2016.8.26.0539; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 9ª

Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 30/11/2020) (Sublinhado meu).

Esclareço, apenas para que não se alegue omissão, ser inaplicável o redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, por tratar-se de reincidente.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

“Apelação - (...) Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa - Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)”. (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (Ênfase na reprodução).

b) Crime do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03:

Como exposto na dosimetria anterior, o réu não possui maus antecedentes, vez que a sua única condenação, com trânsito em julgado, será considerada na próxima fase da dosimetria.

A conduta censurada, porém, merece maior reprovação, posto que, além da posse de arma de fogo (já suficiente para configurar o referido crime), o acusado possuía também munições.

Portanto, tenho por bem estabelecer a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do piso, ou seja, em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multas.

Na segunda fase, verifico a incidência da agravante da reincidência, como, também, da atenuante da confissão espontânea.

Neste ponto, é forçoso mencionar que a confissão espontânea e a reincidência são igualmente preponderantes, na medida em que ambas refletem aspectos sobre a personalidade do agente, a teor do artigo 67, do Código Penal.

Assim, neste caso, pode haver a compensação integral entre essas atenuantes e essa agravante, conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça - STJ (HC 393331/AL - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 23.5.2017 - DJe 26.5.2017; HC 385130/SC - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - T5 - Quinta Turma - Julg. 18.5.2017 - DJe 23.5.2017; HC 338940/SC - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 16.5.2017 - DJe 19.5.2017; HC 352983/RJ - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - T5 - Quinta Turma - Julg. 4.5.2017 - DJe 16.5.2017; HC 392551/SP - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017; HC 392027/RJ - Rel. Min. Ribeiro Dantas - T5 - Quinta Turma - Julg. 2.5.2017 - DJe 8.5.2017).

Mesmo entendimento do nosso E. Tribunal de Justiça, em caso recente e semelhante às circunstâncias do acusado destes autos:

“1-) Apelação Criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida. (...) Na segunda fase, verificou-se que o apelante é reincidente. Por outro lado, há de se reconhecer a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, tendo em vista a confissão judicial, nos termos da Súmula 545, do STJ, pois a admissão de culpa também foi considerada como elemento de convicção na formação do convencimento do julgador. Diante disso, revela-se

proporcional a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, até porque ele ostenta apenas uma condenação definitiva, ainda que específica. (...) 5-) O apelante está preso e deverá permanecer nessa condição". (TJSP; Apelação Criminal 1505697-80.2021.8.26.0263; Relator (a): Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itai - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2022; Data de Registro: 20/01/2022) (Ênfase minha).

Na última fase, não havendo outras circunstâncias modificadoras das penas, torno-as definitivas como estabelecidas na primeira fase.

Por se tratar de concurso material, na forma do artigo 69, do Código Penal, as penas deverão ser somadas, resultando em um total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Com relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, anote-se que o delito de tráfico é equiparado aos crimes hediondos, de acordo com a atual redação do artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 e, por isso, não se mostra razoável a incidência do regime aberto ou semiaberto para o cumprimento da reprimenda, em que pese não seja obrigatório o regime mais gravoso, devido ao C. STF ter reconhecido, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do parágrafo citado (HC 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli).

Porém, convém lembrar, na esteira do julgado citado da Suprema Corte, que isso não invalida a discricionariedade judicial, com possibilidade na análise do caso concreto, de fixação do regime fechado quando entendido como sendo o mais adequado.

No caso dos autos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, à vista das circunstâncias concretas destes autos acima expostas, bem como do montante de pena ora aplicado, forte no artigo 33, § 2º, alínea "a", e § 3º, do Código Penal.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, para ambos os delitos, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte no artigo 43, da Lei 11.343/06, e artigo 60, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar BRUNO APARECIDO CONCEIÇÃO PIRES, qualificado nos autos, por violação aos tipos penais previstos nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, e 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, a uma pena total de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado; e ao pagamento de uma multa no importe de 710 (setecentos e dez) dias-multa, diária mínima (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos), com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do sursis penal.

Nego-lhe, outrossim, o direito de recorrer em liberdade. Com efeito, na data de

hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva do implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente.

Além disso, a pena relativamente alta imposta ao acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual.

Ademais, não faz qualquer sentido soltar um réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado, sem que tenha dado o tempo da detração de que trata o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, ainda mais, quando se trata de réu condenado em concurso de crimes, salientando-se, também, a sua reincidência específica.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também, garantir a ordem pública, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas – Preliminar – Apelo em liberdade – Impossibilidade – Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos – Preliminar rejeitada – Recurso não provido. Tráfico de Drogas – (...) – Recursos providos em parte". (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

Mesmo entendimento das Cortes Superiores: "não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar" (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).

Havendo recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição.

Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, nada a apreciar com relação a elas. Já, com relação à arma de fogo, apreendida na mesma oportunidade, determino a remessa ao Exército para as finalidades cabíveis, nos termos do que dispõe o artigo 25, da Lei 10.826/03.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se guia de execução definitiva ou o seu complemento; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; d) Oficie-se a autoridade policial nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06; e e) Adotadas as cautelas legais, com o trânsito, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA